

1501080-22.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... razão da existência de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (fls. 391).

Cumpra observar que o tráfico privilegiado consiste em punir com menor severidade o "traficante de primeira viagem", ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, o que é incompatível com o histórico infracional do réu, que demonstra que sua efetiva dedicação as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501080-22.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501080-22.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2233471/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 19883597 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2219/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2233471 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2233471 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ, 2219/21/229 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICA REGINA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

ERICA REGINA DA SILVA, VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA e GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos narrados na denúncia de fls. 105/109.

Diante da suspensão das audiências de custódia conforme Recomendação CNJ nº 62/2020

e Comunicado CG nº 232/2020, a legalidade da prisão em flagrante dos acusados VÍTOR e ERICA foi analisada judicialmente, tendo sido convertida em prisão preventiva. Com relação à acusada ERICA, sua prisão preventiva ainda foi convertida em prisão domiciliar, com a imposição de outras medidas cautelares. Na ocasião, em vista da representação do Ministério Público, restou decretada a prisão preventiva do réu GUSTAVO, e determinada a destruição da droga apreendida, tudo conforme decisão de fls. 135/141.

Por decisão de fls. 263, foi determinada a notificação dos acusados para oferecimento de suas defesas preliminares.

Notificados (fls. 282, 284), os acusados apresentaram defesas prévias a fls. 314/317, 319/322 e 324/327.

Recebida a denúncia a fls. 341/344, o feito restou saneado, tendo sido designada audiência de instrução.

Realizou-se audiência de instrução (fls. 456/458), na qual estiveram presentes todos os réus, que foram interrogados ao final dos depoimentos colhidos de três testemunhas arroladas em comum e três testemunhas arroladas pela defesa. Ao final, restou encerrada a instrução e concedido prazo para as alegações finais.

A fls. 462/481, o Ministério Público pugnou pela procedência da acusação, estando comprovadas materialidade e autoria, nos termos da denúncia.

A defesa do réu VÍTOR apresentou alegações finais a fls. 484/497, nas quais requer sua absolvição do crime de associação para o tráfico, ante a ausência de prova quanto a vinculação e estabilidade do suposto grupo composto com os demais réus, bem como pela inexistência de pedido condenatório do Ministério Público em seus memoriais. Quanto ao crime de tráfico, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do redutor previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no máximo permitido.

Pretende, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, com posterior substituição por pena restritiva de direitos ou, na hipótese de fixação do regime semiaberto, que seja revogada a prisão preventiva.

A fls. 498/512 a defesa da ré ERICA apresentou alegações finais em que requer sua absolvição por falta de provas da traficância e pela ausência da demonstração do vínculo e da estabilidade entre as partes para configuração da associação para o tráfico. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, no máximo permitido. Pretende, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, com posterior substituição por pena restritiva de direitos ou, na hipótese de fixação do regime semiaberto, que seja revogada a prisão preventiva.

Por fim, a fls. 513/530, a defesa do réu GUSTAVO apresentou suas alegações finais, nas quais também pretende sua absolvição pela falta de provas a respeito da traficância, bem como pela ausência de demonstração do vínculo e estabilidade das partes para configuração do crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da minoridade relativa e do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no máximo permitido. Pretende, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, com posterior substituição por pena restritiva de direitos ou, na hipótese de fixação do regime semiaberto, que seja revogada a prisão preventiva.

Capítulo II - Da Motivação

Trata-se de ação penal pública incondicionada onde colima o Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação dos acusados ERICA REGINA DA SILVA, VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA e GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

No mérito, a denúncia deve ser acolhida em parte.

A materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 restou devidamente comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, das notas de culpa de fls. 09 e 11, do boletim de ocorrência de fls. 12/15, dos autos de exibição e apreensão de fls. 15/16, dos documentos de fls. 25/29, das

fotografias de fls. 65/68, do laudo de constatação de fls. 69/71, confirmado pelo laudo definitivo de entorpecentes de fls. 237/243 e do relatório final da investigação de fls. 248/254. Também se extrai a materialidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto no decorrer na investigação criminal, quanto em audiência. Aliás, sabendo tratar-se a materialidade da constatação da efetiva ocorrência do delito, pode ser ela caracterizada também através da prova testemunhal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (Neste sentido: TJSC; Ap. crim. n. 00.000473-1; Relator Des. Amaral e Silva).

A autoria dos acusados VÍTOR e GUSTAVO também é certa.

As testemunhas JOSE CICERO DE MELO JÚNIOR e RENATO TEIXEIRA DE BRITO, policiais militares ouvidos em audiência, ratificaram as declarações prestadas em inquérito policial. Disseram que, em razão de denúncias recebidas acerca da suposta traficância praticada na residência da mãe dos acusados ERICA e GUSTAVO e de parentes do réu VÍTOR, foram realizadas algumas diligências que resultaram na representação da Autoridade Policial para a expedição de mandado de busca e apreensão. Em seu cumprimento, dirigiram-se a residência da mãe dos primeiros acusados, tendo sido recebidos pela ré ERICA, que não demonstrou resistência e apontou que as drogas estavam guardadas no quarto de seu irmão GUSTAVO. Além das drogas, a ré também sabia onde estavam as balanças de precisão e dinheiro, demonstrando seu envolvimento com o crime.

Indagado, a testemunha JOSÉ CÍCERO afirmou ter certeza de que os três acusados estavam envolvidos no crime de tráfico, já que constavam expressamente no mandado de busca e apreensão, e que desempenhavam cada qual a venda dos entorpecentes a quem aparecesse no imóvel. Em diligência, chegaram a identificar diversos usuários, que não foram abordados para não prejudicar o restante da investigação.

A testemunha MARSHAL HENRIQUE PACHECO, investigador de polícia também ouvido em audiência, disse que no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado no imóvel na Vista Alegre, prestou apoio na rua de fundos do imóvel. Quando os policiais da DISE invadiram o imóvel, ouviu gritos de que haviam pessoas empreendendo fuga, dentre os quais o réu VÍTOR, que acabou sendo apreendido. Não soube detalhar a respeito do que fora apreendido, tampouco quanto a forma da organização do grupo ou sobre suas atividades ilícitas.

Pela Defesa, inicialmente foi colhido o depoimento de CHARLENE RIBEIRO DE LIMA, prestado na qualidade de informante, que afirmou desconhecer o envolvimento de GUSTAVO e de ERICA com drogas. Afirmou que ERICA possui três filhos e que a família é bastante carente, não ostentando padrão de vida incompatível com a sua renda.

ELAINE GERALDO, também ouvida sem ser compromissada, declarou que é vizinha da casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Disse que nunca presenciou qualquer movimentação suspeita na casa, confirmando que são pessoas humildes que dependem de doações da Igreja.

Indagada, afirmou que ERICA e GUSTAVO moram na casa junto da mãe, SANDRA, a qual também é frequentada pelo réu VÍTOR, também conhecido como "Gordinho", por ser seu namorado.

A testemunha de defesa, THAYANE CRISTINA CONTI DE MOURA, disse conhecer a família de GUSTAVO e ERICA há cerca de 10 anos, nunca tendo ouvido qualquer boato de que tenham envolvimento com drogas. Disse que são pessoas bastante simples e que não ostentam um padrão de vida incompatível.

Em seus respectivos interrogatórios, os réus GUSTAVO e ERICA negaram qualquer envolvimento com os crimes em análise.

O réu GUSTAVO disse que, na época dos fatos, não estava mais morando na casa de sua mãe, pois estava arrumando uns "bicos de pedreiro" e passava a maior parte do tempo na casa de sua avó. Disse ter tido ciência de que seu antigo quarto era usado para armazenagem de droga somente por meio de seu advogado, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Indagado, negou que estivesse na casa de sua mãe no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e que tenha se evadido.

A ré ERICA afirmou que, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, estava em sua casa com os filhos, quando foi surpreendida pela invasão da polícia, sem que tivesse tempo de atender ao portão. No momento em que entraram no imóvel,

deram ordem para que ficasse no sofá com as crianças, enquanto realizavam a busca. Negou que tenha informado onde estavam as drogas, uma vez que sequer tinha ciência de sua existência, tendo sido surpreendida.

Por sua vez, o réu VÍTOR confessou expressamente a traficância e assumiu a propriedade integral das drogas apreendidas. Disse que fazia cerca de duas semanas que ele estava traficando na esquina da rua da casa de sua namorada e que acabou escondendo a droga no guarda-roupa do cunhado, por saber que ele não andava frequentando o imóvel. Negou a participação ou envolvimento dos demais acusados na traficância, dizendo se arrepender por tê-los exposto a essa situação que acabou por incrimina-los injustamente.

Pois bem.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao confitente" ("Da Prova no Processo Penal", p. 79, ed. Saraiva).

E mais:

"A confissão, corroborada por prova judicial convincente, autoriza o reconhecimento da autoria dos delitos, com a conseqüente condenação" (Apelação criminal nº 96.008061-9, de Videira, Relator Des Souza Varella).

A respeito, traz-se à colação:

"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade é afastada a mais remota hipótese de autoimputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Sendo assim, ainda que a confissão do réu confirme sua responsabilidade pela traficância, em atenção ao conjunto probatório reunido dos autos, entendo que não foi suficiente para afastar a autoria do crime imputado ao corréu GUSTAVO.

Isso porque, além da própria informante ELAINE os contradizer, afirmando que ele ainda residia na casa de sua mãe, juntamente com a ré ERICA, os interessados não trouxeram qualquer documento que comprove que ele estava fazendo os tais "bicos de pedreiro", tampouco que para desempenha-los precisou mudar-se para a casa de sua avó.

Além disso, conforme consta no boletim de ocorrência, além da droga encontrada em seu guarda-roupa, também foi localizada uma quantia de dinheiro em "trocados" no bolso de sua bermuda, o que sequer restou impugnado ou mesmo esclarecido.

Saliente-se que, conforme confirmado pelos três policiais ouvidos em audiência, o réu GUSTAVO já era conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, de forma que, se não comprovou a sua desvinculação com as evidências reunidas nos autos, não se desincumbiu igualmente do seu ônus probatório.

Aliás, sobre o ônus da prova, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional, soa adequado rememorar, com esboço na lição de Aury Lopes Júnior, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, "entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações" (Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris,

2009, pag. 45). Em outras palavras, segundo o ensinado professor Aury Lopes:

"O que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa". (Grifo no original) (ob. cit.).

Sendo assim, caberia tão somente ao réu a prova de suas alegações defensivas. Contudo, a parte tão somente alegou, não se desincumbindo do ônus insculpido no caput do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com relação à ré ERICA, ainda que soubesse o local onde poderiam estar as drogas e balanças, tal conhecimento não é suficiente para imputá-la aos crimes em análise, sobretudo por considerar a relação de parentesco e habitação comum com os demais envolvidos.

Ora, se suspeitasse ou mesmo soubesse que o irmão estava guardando drogas em seu quarto, sequer seria obrigada a denunciá-lo, por força do que se extrai do §2º do artigo 348 do Código Penal e artigo 206 do Código de Processo Penal.

Além disso, conforme revelado pelas informantes e confirmado pela testemunha de defesa, a ré é mãe de três filhos pequenos, depende de ajuda beneficente da igreja e nunca levantou suspeitas acerca da traficância, isso que, inclusive, foi confirmado pelos policiais e mesmo por sua folha de antecedentes.

Sendo assim, inexistindo prova segura de que tenha efetivamente cometido quaisquer dos verbos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. No mesmo sentido, deve ser afastada a imputação pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Antidrogas.

É que, a despeito de as provas dos autos demonstrarem a participação conjunta dos acusados GUSTAVO e VITOR no tráfico ilícito de entorpecentes, a verdade é que as circunstâncias do fato versado no presente feito indicam mais um mero concurso de agentes existente entre eles para a guarda e venda das substâncias entorpecentes do que uma verdadeira associação que pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade e vínculo hierárquico havido entre todos os acusados.

É o que tem entendido a doutrina a respeito: "Observe-se que o delito está a exigir, além de duas ou mais pessoas, que o vínculo associativo para a formação da quadrilha ou bando visando ao tráfico ilícito de entorpecentes seja estável e permanente. Observa Vicente Greco Filho que: Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece, todavia, que não será toda a vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a prática de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria" (Marcello Ovídio Lopes Guimarães, Nova Lei Antidrogas Comentada - Lei n. 11.343, São Paulo, Quartier Latin, 2007, p.175-176).

Nesse sentido, também são as lições de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Henrique Aranda Füller, os quais, ao comentar o delito tipificado no artigo 35, "caput", da Lei de Drogas, afirmam que "a compreensão sobre a necessidade de permanência e estabilidade decorre da teoria do bem jurídico, eis que, sem a reunião estável, não há qualquer risco autônomo ao bem jurídico paz pública. O mero planejamento para uma eventual conduta de traficância em conjunto fica evidentemente absorvido pelo próprio crime de tráfico, que exaure o potencial lesivo do planejamento, sem

merecer relevância penal autônoma. Como não é possível crime sem lesão ou risco de lesão ao bem jurídico, a única interpretação viável e constitucional do artigo é que, para a tipificação da conduta, persiste sendo necessária estabilidade e permanência, como crime de quadrilha do Código Penal, diferenciando-se daquela figura pelo elemento subjetivo (não basta querer praticar qualquer crime, mas apenas os previstos nos arts. 33, caput e § I, 34 e 36 da lei de drogas) e pelo número de agentes (para o código penal, um mínimo de quatro, enquanto na lei de drogas são necessários dois)." (Lei de Drogas, em Legislação Penal Especial, 4ª edição, volume I, Premier máxima, pág. 250).

Assim, diante da ausência de comprovação da efetiva associação entre os agentes voltada ao cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, de rigor a absolvição dos acusados em relação à imputação de prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Em conclusão, incorreram tão somente os acusados VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA e GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Capítulo III - Da Dosimetria

III.B - Do acusado GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS

Na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, e às do art. 42 da Lei n. 11.343/06, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal a espécie. À época do crime, o réu não possuía maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ, conforme se observa em sua folha de antecedentes e certidão de fls.

386/391. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos suficientes para avaliação percutiente. As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que o réu utilizava a casa de sua mãe, na presença de seus próprios sobrinhos ainda infantes, para fazer depósito de drogas de natureza extremamente danosas ("crack"), colocando-as em grande risco. Os motivos e as consequências do crime não foram apurados. Por estas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, mas sim a atenuante de menoridade relativa prevista no artigo 65, I do Código Penal, uma vez ter nascido em 07 de agosto de 2002, sendo que na data dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade, de forma que reduzo a pena intermediária em 1/6, no total de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, inexistindo causas majorantes da pena, entendo também não ser o caso da aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da existência de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (fls. 391).

Cumprir observar que o tráfico privilegiado consiste em punir com menor severidade o "traficante de primeira viagem", ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, o que é incompatível com o histórico infracional do réu, que demonstra que sua efetiva dedicação às atividades criminosas de modo reiterado e, desse modo, inviável tal benesse. Nesse sentido, em consonância tem a jurisprudência decidido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o

entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, tal como na espécie, notadamente diante da manutenção da circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 488.570/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/8/2019).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o recorrente se dedica costumeiramente a atividades criminosas. Tal conclusão encontra-se amparada em documentos que reportam os atos infracionais praticados pelo recorrente quando ainda era menor de idade, bem como na quantidade de droga apreendida e no fato dos policiais terem ressaltado a existência de inúmeras denúncias dando conta do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, além do que, durante a breve observação que realizaram no dia dos fatos, visualizaram no em negociação com três pessoas diferentes, tudo a reforçar a convicção quanto a sua dedicação intensa e exclusiva ao exercício dessa atividade criminosa. Desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar Maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, como na espécie, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1812378/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/4/2021).

Sendo assim, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

No que concerne à pena pecuniária aplicada, o valor de cada dia multa será de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do CP, bem como artigo 43, da Lei nº 11.343/2006, em razão da falta de prova acerca a condição econômica do réu.

Tendo em vista a natureza do crime, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o acusado iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos ou ainda a suspensão condicional de sua execução, pois o réu não preenche os requisitos previstos nos incisos dos artigos 44, incisos I, II e III e 77, caput e inciso I e II, ambos do Código Penal.

III.B – Do acusado VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA

Na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, e às do art. 42 da Lei n. 11.343/06, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal a espécie. À época do crime, o réu não possuía maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ, conforme se observa em sua folha de antecedentes e certidão de fls. 393/401. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos suficientes para avaliação percutiente. As circunstâncias devem ser valorada negativamente, uma vez que o réu utilizava a casa de sua namorada, na presença de crianças, para fazer depósito de drogas de natureza extramamente danosas ("crack"), colocando-as em grande risco. Os motivos e as consequências do crime não foram apurados. Por estas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa. Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, mas sim a atenuante de confissão espontânea do agente, conforme previsto no artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal, de forma que reduzo a pena intermediária em 1/6, no total de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, inexistindo causas majorantes da pena, entendo também não ser o caso da aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, conforme confessado pelo réu, ele tem feito do tráfico um meio de vida, dedicando-se a tal atividade criminosa, de forma que igualmente responde ao mesmo crime nos autos do processo de nº 1501256-35.2020.8.26.0637, onde já fora condenado em primeira instância (fls. 398).

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Além disso, o réu também detém vasto histórico de envolvimento com o tráfico, tendo respondido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 401), prejudicando-lhe o reconhecimento do redutor pretendido.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

No que concerne à pena pecuniária aplicada, o valor de cada dia multa será de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do CP, bem como artigo 43, da Lei nº 11.343/2006, em razão da falta de prova acerca a condição econômica do réu.

Tendo em vista a natureza do crime, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso, a quantidade da pena aplicada e a notícia de cometimento de falta grave pelo réu (fls. 536), fixo o regime fechado para o acusado iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos ou ainda a suspensão condicional de sua execução, pois o réu não preenche os requisitos previstos nos incisos dos artigos 44, incisos I, II e III e 77, caput e inciso I e II, ambos do Código Penal.

Por último, nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica de ambos os réus ora condenados, remanescendo o panorama que o levou à conversão de suas prisões em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida

anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Ressalte-se que imperativa a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública já que evidenciada completamente a autoria e a materialidade do delito, conforme discriminado na fundamentação, havendo seríssimos riscos de que os réus venham novamente a delinquir enquanto não cumpram a pena, sendo que o corréu Vítor é ainda reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, utilizando-se de práticas ilícitas como seu meio de vida. Além disso, possível concluir que as reprimendas anteriores não foram suficientes para que ele se arrependesse de ter ingressado no mundo criminoso, o que coloca em sérios riscos a incolumidade social, a paz pública e a credibilidade da justiça.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade dos réus ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º).

Assim, mantenho a prisão preventiva dos réus GUSTAVO e VÍTOR, porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e em homenagem ao Princípio da Homogeneidade das Prisões.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Capítulo IV - Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

- 1) ABSOLVO a acusada ERICA REGINA DA SILVA, das acusações dos crimes previstos nos artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, VII do Código Penal;
- 2) ABSOLVO o acusado GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS, da acusação do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, VII do Código Penal;
- 3) ABSOLVO o acusado VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA, da acusação do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, VII do Código Penal;
- 4) CONDENO o acusado GUSTAVO WILLIAN DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43, da Lei nº. 11.343/06;
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelos motivos expostos e CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.
- 5) CONDENO o acusado VÍTOR BARBOSA MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43, da Lei nº. 11.343/06.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelos motivos expostos.

Não reconheço aos réus GUSTAVO e VÍTOR ao direito de recorrer em liberdade pelos motivos já expostos. Tendo em vista que os réus estão presos cautelarmente por este processo, recomende-se-os no local onde estão presos, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Serve o presente de ofício.

Em que pese à alteração legislativa levada a efeito com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, deixo de aplicá-la em sua integralidade.

Ora, tratam-se de dispositivos manifestamente inconstitucionais, posto que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.

Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio

constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

Por outro lado, ante a absolvição da acusada ERICA REGINA DA SILVA, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM SEU FAVOR.

No mais, cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino à Serventia as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis (art. 15, III, da Constituição Federal); 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva (art. 105 da Lei de Execução Penal), ou provisória, em caso de recurso; 5) Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Custas pelos réus GUSTAVO e VITOR, ficando-lhes concedido os benefícios da gratuidade processual.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, se o caso.

P.I.

De São Paulo para Tupã, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA